

1500977-09.2020.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... motivos do crime e as circunstâncias são naturais ao tráfico de drogas, bem como as consequências dele decorrentes, nada havendo a valorar. O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, então, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, na fixação da pena-base, considerando a variedade e a quantidade das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500977-09.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500977-09.2020.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO CESAR SENA

Vistos.

Danilo Cesar Sena foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque por volta das 15h10min de 27 de setembro de 2020, na rua Benedito Silva, nº 25, São Gonçalo, Taubaté, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de venda e entrega a terceiros, 237 pedras de crack, com massa líquida de 42,65 gramas, 500 papелotes prensados de cocaína, com massa líquida de 409,09 gramas, e 26 buchas de maconha com massa líquida de 96,39 gramas.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, o réu se deslocou ao endereço acima descrito, conhecido ponto de venda de drogas, e escondeu dentro de um terreno baldio uma sacola contendo parte dos entorpecentes. Ocorre que, em patrulhamento de rotina, policiais se depararam com o acusado no local e, diante do seu comportamento suspeito, resolveram abordá-lo. Após revista pessoal, foi localizada com ele algumas porções de drogas, ao passo que a sacola foi apreendida com outras

porções de drogas.

A denúncia foi recebida às fls. 95/97.

Citado (fls. 106), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 111.)

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, a acusação e a defesa apresentaram alegações finais por meio de memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Destacou a prova testemunhal colhida em juízo e durante o inquérito. Aduziu que a negativa de autoria não encontrou respaldo em outras provas dos autos. Enfatizou a quantidade de drogas apreendidas no local dos fatos. Argumentou que é plenamente possível o exercício do narcotráfico por usuários de drogas. Defendeu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em especial pela natureza e quantidade das drogas. Rechaçou a possibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Pediu a fixação de regime inicial fechado e o perdimento dos valores apreendidos.

A Defesa pediu a absolvição do réu por falta de provas. Argumentou que as narrativas dos policiais se mostraram controvertidas. Destacou que o acusado não foi visto mexendo na sacola que continha drogas apreendida pelos policiais ou exercendo atos de mercancia ilícita. Defendeu a negativa de autoria apresentada em juízo, destacando que o acusado é apenas usuário de drogas. Requereu a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Pediu imposição de regime inicial aberto ou, no máximo, semiaberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público atribuiu ao réu a autoria de tráfico de drogas, dando-o como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade e a autoria delitivas estão escoradas em termos de depoimentos (fls. 2/3), termo de interrogatório (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 17/20), laudos toxicológicos (fls. 68/70 e 71/73) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha Daniel Trevisan disse que estava em patrulhamento pelo bairro, local conhecido pelo tráfico. Visualizou o réu parado, que apresentou nervosismo com a aproximação da polícia. Submetido à abordagem, com o réu foram encontradas 20 pedras de crack, R\$ 75,00 e um telefone celular. Questionado, o acusado disse que era responsável pela guarda da droga e estava ali desde às 8 horas. O réu afirmou que havia outras duas pessoas que se evadiram antes da abordagem policial. Em busca pelo local, foram encontradas outras drogas (cocaína, crack e maconha) em uma sacola. Indagado, o acusado informou que não sabia das drogas armazenadas na sacola e acreditava que pertenciam aos outros indivíduos que fugiram. Aduziu que o réu não indicou a localização das drogas, que foram achadas em razão de diligências policiais. Afirmou que o réu não foi visto mexendo no local onde as drogas foram encontradas. Relatou que as drogas que estavam na posse do réu eram semelhantes àquelas armazenadas na sacola. Informou que as pedras de crack estavam embaladas em plástico transparente. Disse que havia apenas drogas na sacola. Não conhecia o réu nem havia recebido denúncia contra ele. Afirmou que o réu não resistiu à abordagem

e a sacola foi encontrada a aproximadamente 10 ou 15 metros de distância dele.

Jonas Zanin, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo bairro. Relatou que o réu foi abordado em um conhecido ponto de venda de drogas. Disse que foram encontradas porções de crack com o réu. Questionado, o acusado falou que estava na biqueira desde o período da manhã. Aduziu que outras drogas foram encontradas em uma sacola, mas o réu negou a propriedade dos objetos. Segundo o acusado, as drogas possivelmente pertenciam a dois indivíduos que fugiram antes da aproximação da polícia. Informou que as porções de crack encontradas com o réu eram semelhantes àquelas guardadas na sacola, que também continha maconha e cocaína. Não conhecia o acusado. Não visualizou outras pessoas no local. Disse que o réu não ofereceu resistência à abordagem. Estimou que a sacola com drogas estava a dez metros do réu.

Interrogado, o réu negou a autoria do crime. Disse que estava enfrentando uma fase avançada do vício em drogas. Afirmou que permaneceu o dia inteiro no local, onde comprou drogas naquela manhã e desceu a rua. Asseverou que havia comprado 20 pedras de crack por R\$ 10,00 cada. Informou que estava caminhando em direção a uma casa utilizada por usuários para consumo de drogas. Disse que havia comprado as drogas instantes antes de ser abordado. Afirmou que os policiais não exibiram a sacola de drogas por eles encontrada. Disse que trabalha há oito anos em uma fábrica. Informou que já se submeteu à internação por duas vezes. Afirmou que consumia drogas durante todo o dia, chegando a permanecer mais de um dia sob efeito de drogas. Disse que, no ápice do consumo de drogas, já consumiu mais de 30 pedras de crack em um dia. Informou que era possível gastar todo o salário, superior a mil reais, em drogas.

Ao cabo da instrução, resultaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

Observo que a conduta do réu se enquadra em ao menos um dos verbos-núcleo do tipo, notadamente guardar, ter em depósito e trazer consigo diversas porções individuais de drogas para fins de tráfico, resultando configurada a tipificação do crime em destaque.

A própria prisão em flagrante comprova que o réu mantinha em depósito, guardado em uma sacola, mais de 400 gramas de cocaína, quase 100 gramas de maconha, mais de 200 porções de crack, além de trazer consigo outras 20 porções de crack.

Em adição à prisão em flagrante, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais foram coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo com fidelidade o quanto afirmado durante a fase do inquérito, dando conta do ocorrido na data dos fatos. Ambos desceram a minúcias, retratando o fato como realmente passado, dizendo como se deu a prisão e as demais circunstâncias em que foram encontradas as drogas com o réu.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalto que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa

condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Diante disso, não se há dar guarida à versão do réu de que estava no local com intenção de apenas comprar porções de drogas para seu consumo pessoal.

Com efeito, a argumentação do réu de que havia outras pessoas no local, as quais conseguiram fugir antes da aproximação da viatura policial não encontra respaldo nas demais provas dos autos. Os policiais não vislumbraram as supostas pessoas que estavam junto ao acusado, cabendo registro que deveria o réu fornecer elementos de provas a demonstrar suas alegações.

Ao contrário, os agentes públicos enfatizaram que presenciaram o réu sozinho, que apresentou nervosismo com a presença da polícia. Disseram que as porções de crack encontradas em seu bolso eram iguais àquelas armazenadas em uma sacola, não mais distante que dez metros de onde o acusado foi abordado.

Se realmente fosse mero consumidor de drogas, caberia ao réu demonstrar a origem da quantidade de dinheiro que carregava ao chegar naquele conhecido ponto de venda de drogas, em torno das oito horas da manhã, conforme por ele informado, quantas porções de drogas já havia consumido e por que ainda mantinha consigo outras vinte pedras de crack e setenta e cinco reais. Não há motivo para carregar consigo a expressiva quantidade de drogas com as quais foi preso, além da quantia em dinheiro trocado com ele localizada, enquanto permanece na "biqueira" por mais de sete horas ininterruptas.

Como assentado no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, e a forma como elas estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes" (Apelação nº 3004054-64.2013.8.26.0272, Rel. Luís Augusto de Sampaio Arruda, j. 20.7.2017).

Com relação à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, observo que não é o caso de reconhecê-la, pois o réu, apesar de não ser reincidente, foi preso com variedade e quantidade de drogas que impede a aplicação da benesse.

Acerca da questão, cabe ser ressaltado que a redução prevista na lei busca alcançar e tem por finalidade aquele pequeno traficante, o traficante fortuito. É a ele que a lei visa a conceder a benesse, promovendo-lhe uma nova chance para que se ajuste ao meio social em que vive.

No caso concreto foram localizadas e apreendidas diversas porções de drogas, com peso superior a meio quilograma, indicativo mais que manifesto da dedicação do réu ao narcotráfico e seu profundo envolvimento com ele, justificando assim a não aplicação da causa de diminuição de pena.

Nesse caminho trilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Note-se, a propósito, que de acordo com o disciplina inserta na Lei 11.343/06, a quantidade de droga é um dos relevantes parâmetros a serem considerados, tanto no reconhecimento típico do tráfico, quanto em relação à dosimetria da pena, sem que se possa falar em bis in idem, por força mesmo do que dispõe o artigo 42 da norma. Isto porque não se mostra razoável que alguém manejando grande quantidade de droga ostente a condição de traficante eventual, de modo a fazer jus à benesse do legislador. Assim, interpretando o dispositivo legal em comento, esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais" (AgRg no Recurso Especial Nº 1.325.910 - SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 11.4.2014).

Em abono à tese, trouxe o v. acórdão os seguintes julgados:

"O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa." (HC 130.514/SP, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), quinta turma, DJe 03.02.2012).

"Conforme corretamente se pronunciaram os graus de jurisdição antecedentes, em razão da expressiva quantidade e natureza de droga apreendida, resta evidenciado que os Pacientes são pessoas dedicadas à criminalidade ou integrantes de organização criminosa, o que impede a redução de pena pretendida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça." (HC 214.286/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, quinta turma, DJe 29.06.2012).

Quem é apanhado, como aqui, armazenando e carregando em plena via pública grande quantidade de drogas, já embalada para entrega e consumo imediato, não tem como justificar outra situação senão aquela que aos olhos salta: traficância.

Dessa forma, não há qualquer dúvida acerca do fato e da responsabilidade do réu pelo evento criminoso, pois tinha pleno conhecimento da ilicitude e, mesmo assim, decidiu determinar-se nesse caminho.

A prova é certa, segura e dá conta do cometimento do crime pelo réu, que deve responder pelo ilícito praticado.

Estabelecida a responsabilidade do réu, passo à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nelson Hungria e obediente à individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A quantidade da droga pesa em desfavor do réu, pois se trata de expressiva quantidade de maconha, cocaína e crack (237 pedras de crack, com massa líquida de 42,65 gramas, 500 papélotes prensados de cocaína, com massa líquida de 409,09 gramas, e 26 buchas de maconha, com massa líquida de 96,39 gramas), drogas já individualizadas e embaladas para serem entregues aos usuários consumidores, o que justifica o aumento da pena-base.

A personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da

pena, RT, 2005, p. 207) – se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017:

“...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexactidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade”

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo “A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena”, da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

“...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro

judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais comezinhos da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, “estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade” (“A mentira do réu e a Dosimetria da Pena”, artigo de autoria do Promotor de Justiça André Wagner Melgaço Reis, disponível em).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

“...demaís disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o

patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

“Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base...”

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

“Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decísum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP, Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP, Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3^a Vara Criminal, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372 (1^a

Vara Judicial de Hortolândia, Juiz de Direito Luís Mário Mori Domingues j. 21.01.2015):

“(...) escoreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida” (TJSP, Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625; 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Ivana David, j. em 10.12.2019)

O réu não possui antecedentes criminais. Acerca da conduta social do réu não se tem elementos para sua valoração. Os motivos do crime e as circunstâncias são naturais ao tráfico de drogas, bem como as consequências dele decorrentes, nada havendo a valorar. O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, então, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, na fixação da pena-base, considerando a variedade e a quantidade das drogas, além da personalidade negativa do réu, elevo a pena em 1/3, alçando-a para 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a reprimenda inalterada.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento, fixando-se definitivamente a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, em razão da quantidade de pena e das circunstâncias negativas que ensejaram majoração da pena ao réu na primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 33, §§ 3º e 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Ademais, trata-se de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta no caso concreto, especialmente pela grande quantidade de entorpecentes apreendida, também exige maior rigor por parte do Estado.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “A quantidade de droga apreendida revela a gravidade concreta do delito, justificando a imposição do regime inicial fechado na hipótese dos autos”. (STJ, HC 315.829/MG, Rel. Ministro Ericson Maranhão, 6ª Turma, julgado em 26/05/2015).

Pela quantidade de pena e pelas circunstâncias do caso concreto, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que exige apenação inferior a 4 anos, e a suspensão condicional da pena, nos termos que dispõem os artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Anoto que, desde a conversão da prisão em flagrante em liberdade provisória, o acusado não esteve recluso por este

processo, não se vislumbrando necessidade de alteração desse estado, pois ausentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas 'b' e 'c'. Nesse sentido: (STJ, HC 169.072/SP, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 10.6.2010).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência. Registro que a vítima é a sociedade.

Declaro o perdimento de todos os valores apreendidos (fls. 51) em favor da União Federal, pois não foi comprovada a origem lícita do dinheiro encontrado na posse do réu.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com ao artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Danilo Cesar Sena à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, iniciando-se o cumprimento em regime fechado, concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 8 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA